

1520774-06.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e tipo de drogas apreendidas em poder do réu, e ainda o dinheiro miúdo também apreendido com ele, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Tanto é assim que os guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520774-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520774-06.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2247543/2022 - 8º Distrito Policial - Brás, GE2702-1/2022 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL EVERTON TENÓRIO SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1305/22

VISTOS.

SAMUEL EVERTON TENÓRIO SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque consta que no dia 09 de setembro de 2022, por volta de 11h20, Praça da Sé, 10, São Paulo, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, cerca de 2g de cocaína, e 3,8g de cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão e laudo de constatação.

A denúncia foi recebida a fls. 67/68.

Foi apresentada defesa preliminar.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, desclassificação para uso, fixação da pena mínima com regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, dando conta dos 24 microtubos de crack, além de R\$ 286,00, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 86/88 atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína.

A autoria também é inconteste.

De fato, a negativa do acusado, secundada pelos argumentos de sua defesa técnica não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na fase inquisitiva o réu negou a propriedade das drogas apreendidas e dos R\$ 286,00, fls. 06. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, negou a acusação dizendo que eu estava preso em outro tráfico tentei ficar sossegado na rua, tentei trabalhar, nos dois primeiro meses consegui trabalhar, mas acabei caindo no vício da droga de novo. Pelo fato de não ter mais dinheiro e ter me viciado na droga, perdi o emprego, sai de perto da minha família, perambulando pela rua, não tinha mais dinheiro, e para sustentar meu vício, acabei na Praça da Sé. Acabei conhecendo aquelas pessoas no fluxo, por conta de eu estar usando, recebi a droga para poder vender e consumir também. Então confesso que realmente estava com as drogas para venda. Não conhecia os guardas civis metropolitanos. Eu só tinha as drogas que estavam comigo, as demais drogas eram do outro rapaz, que forjou que era minha. É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo o édito condenatório. Mas é certo também que quando vem acompanhada dos demais elementos probatórios, como no presente caso, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

Tanto é assim que as imagens das câmeras de filmagens falam por si e prescindem de maiores divagações a respeito.

É possível ver a conduta do acusado em típica ação de traficância.

Não se pode crer que o réu estivesse, justamente no local dos fatos, com as características mostradas nas imagens das câmeras de filmagens, quando fosse do nada, preso pelos policiais e acusado da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele, efetivamente guardando as drogas e arma descritas na denúncia. Desta forma, não se tem nos autos, a despeito dos argumentos da Doute Defesa, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusa-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e tipo de drogas apreendidas em poder do réu, e ainda o dinheiro miúdo também apreendido com ele, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Tanto é assim que os guardas civis metropolitanos responsáveis pela prisão do réu, Paulo Henrique Vicente de Oliveira, Manoel Sobrinho de Sousa, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme, segura e em uma só voz que estávamos em serviço, quando fomos acionados pela nossa central, informando as características de dois indivíduos, com camisa amarela de futebol. Fomos ao local, identificamos o réu cujas características coincidiam. Abordamos o réu e a testemunha, em poder do réu foi encontrado 6 porções de cocaína e 286 reais em dinheiro. A central informava que dois indivíduos estavam fazendo tráfico de entorpecentes no local. As

pedras de crack estavam próximo ao réu em um maço de cigarros. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente.

Os guardas civis narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde o patrulhamento, a chegada ao local, quando foram acionados pela Central de Monitoramento, informando que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes pelo local, o momento em que viram o réu e o indivíduo Raildo no local dos fatos, abordagem o encontro das drogas com o réu Samuel e o dinheiro apreendido, com Raildo nada foi localizado, até final detenção e prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos.

Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas e dinheiro encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, condenado de forma definitiva por dois roubos, conforme certidões de fls. 31/32, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. Assim nesta primeira fase, elevo sua pena base em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente específico, conforme certidão de fls. 31. De outro giro, confessou espontaneamente a autoria do crime, de sorte que mantenho a pena base, eis que tais circunstâncias, a meu ver se compensam. Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa preponderante sobre a confissão. Ocorre porém que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam, buscam eximir-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual. Não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado é reincidente específico, além de possuir maus antecedentes circunstâncias estas suficientes a afastarem os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação da redução em apreço, nada havendo portanto, que demonstre que não faz do crime um meio de vida.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar MATHEUS DA SILVA PEREIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, pois o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê expressamente, que crimes dessa natureza, terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado.

Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau.

Não é possível também a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram. No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever:

“Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no esgarçamento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco

e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Além disso, não encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal.

Qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade e em regime fechado, mostrar-se-ia por demasiado tênue, como forma de repressão e retribuição. De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, o condenado respondeu a todo o processo preso e assim deve permanecer, pois foi nesta data condenado a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06. A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem. Assim sendo, presentes os requisitos legais, não concedo ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento

na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Após o transito em julgado desta, com a perda do dinheiro apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA